UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

NOVA GRADUAÇÃO UNIVERSIDADE LA SALLE

UNIDADE 1

Direito DIGITAL

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

unidade
1
V.1 | 2023

O Direito na Contemporaneidade

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Apresentar os conceitos básicos e introdutórios ao Direito, com a necessária contextualização à contemporaneidade.

Editora
LaSalle

INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

unidade
1
V.1 | 2023

Parte 1

Direito, Sociedade e Novas Tecnologias

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Direito, sociedade e novas tecnologias

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Definir Revolução 4.0 e seu impacto na sociedade, na indústria e nas relações de trabalho.
- Relatar o surgimento e a evolução das novas tecnologias de informação e comunicação.
- Identificar as mudanças, na sociedade e no direito, que decorreram das novas tecnologias.

Introdução

Diante das mudanças no mundo, com o desenvolvimento da economia industrial, houve várias transformações, denominadas revoluções industriais, conforme se baseou cada momento da indústria. Seu primeiro momento foi de produção a vapor. Depois, foi a vez da produção movida por eletricidade, com o impulso dos meios de comunicação em massa e informação. Até que se chegou na Quarta Revolução Industrial, com a internet e as telecomunicações, que mudaram o jeito de produzir mediante a globalização.

Neste capítulo, você vai estudar a Quarta Revolução Industrial e seu impacto na sociedade, na indústria e nas relações de trabalho. Vai acompanhar o surgimento e a evolução do computador, da internet e das tecnologias de informação. Por fim, vai conferir as mudanças na sociedade e no direito com as novas tecnologias, que estão proporcionando uma revolução paradigmática e cultural entre vários países no mundo.

Revolução 4.0: sociedade, indústria e relações de trabalho

O planeta está em ritmo acelerado na evolução tecnológica, principalmente com novas tecnologias surpreendentes, inusitadas e inovadoras. Conforme o referido ritmo, profissionais de várias áreas e o meio acadêmico estão considerando que ultrapassamos a Terceira Revolução Industrial. O mundo, o direito e a sociedade estão vivendo, atualmente, a Quarta Revolução Industrial, com novas perspectivas e características.

A Primeira Revolução Industrial ocorreu no século XVIII na Inglaterra, quando foram inventadas a máquina a vapor para produção de mercadorias, principalmente roupas, e as locomotivas movidas a vapor, com trens nas estradas de ferro, o que provocou grandes mudanças e o início do capitalismo industrial. Surgiram, então, a maquinofatura (fabricação de produtos por meio de máquinas), a utilização do carvão como fonte de energia e o telégrafo (HOBSBAWM, 2011). Da metade do século XIX até a década de 1930, foi o período da Segunda Revolução Industrial, quando foi inventado o motor a combustão, descobriram-se o petróleo e a eletricidade como fontes de energia para as máquinas, além de motores elétricos e a explosão. Esse período foi marcado por grandes produções industriais em massa, destacando-se o fordismo como modo de produção, que virou símbolo do capitalismo no século XX. De 1950 até 2000, aconteceram grandes transformações do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro e a revolução tecnocientífica, que transformou, exponencialmente, a produção em massa com o auxílio de produção mecatrônica (robotizada). Nesse período, foram inventados os primeiros computadores, houve a evolução da biotecnologia e a conquista espacial pelo homem, o que provocou o processo produtivo com a evolução tecnológica, consolidando o aumento de empresas multinacionais.

A Quarta Revolução Industrial, segundo Schwab (2019), é totalmente diferente das revoluções industriais anteriores, com transformações de velocidade, amplitude, profundidade e impacto sistêmico. As revoluções industriais anteriores seguiam determinadas bases de fontes principais de energia para produção em série, como foi o caso das máquinas a vapor e da eletricidade. A Revolução 4.0 acontece e evolui de modo exponencial — não fica presa de modo linear na produção em série, mas tem característica marcante com a velocidade. Em relação a tecnologias, com mudanças de paradigmas em várias áreas e de forma setorial, a Revolução 4.0 provoca uma grande amplitude (ampliada transformação em vários setores industriais) e profundidade (incorporações de novas pesquisas tecnológicas na produção industrial, que

aumentam seu ritmo de modo grandioso). Acontece com a fusão de várias áreas, envolvendo computação quântica, energias renováveis, nanotecnologia e inteligência artificial, o que proporciona interações tecnológicas fomentadas na disseminação de inovações possíveis.

Em relação ao impacto sistêmico, a Revolução 4.0 provoca transformação de sistemas inteiros, que envolvem empresas, indústrias, a sociedade e vários países. É perceptível a modificação das sociedades, nos seus comportamentos e relações sociais, inclusive no que tange a resoluções de conflitos e normatizações da vida social. Por isso, o direito, como ciência social aplicada, também se modifica, por razões de desenvolvimento de tecnologia, transformações socioeconômicas decorrentes das referidas transformações e questões jurídicas inusitadas. Como exemplo dessa última, podemos citar quando há necessidade de se definirem questões complexas como inteligência artificial, *blockchain*, robótica, entre outras, que aos poucos são judicializadas (levadas à Justiça, no Poder Judiciário, para solução de conflitos).



Saiba mais

Blockchain é uma rede que funciona com blocos cadeados seguros e que carregam conteúdo a uma impressão digital. Tais blocos geram informações significativas, como as criptomoedas (moedas virtuais), a exemplo da *bitcoin*.

Há, também, a exigência de novas habilidades de acordo com as novas tecnologias, de produtividade, eficiência e agilidade na resolução de problemas nos escritórios. As empresas precisam ter plataformas digitais com menos custos e buscar soluções tecnológicas para aprimorar serviços jurídicos, uma vez que impactam o direito e a advocacia em si, acarretando transformações no mundo das corporações para resolver questões legais e contratuais. Outras questões estão envolvidas, como o aumento expressivo de concorrência e o incremento de riscos com novas tecnologias (como crimes cibernéticos).

As equipes multidisciplinares fazem a Revolução 4.0 ser analisada e interpretada com um olhar interdisciplinar e multidisciplinar. Interdisciplinar porque envolve várias áreas do conhecimento, como direito, economia, tecnologia da informação, sociologia, política e antropologia. Multidisciplinar porque converge os conhecimentos para um olhar paradigmático com o auxílio do direito digital, direito civil, direito empresarial, direito internacional, direito de propriedade intelectual, macroeconomia, economia corporativa, sistemas de tecnologia de informação, engenharia de *softwares*, robótica e inteligência

artificial, sociologia cultural, sociologia corporativa, políticas públicas, relações internacionais, antropologia sistêmica e antropologia cultural.

Portanto, diante da Revolução 4.0, há de se observar como evoluiu a tecnologia da informação em si e as tecnologias de comunicação, pois toda essa realidade atual teve consequências jurídicas, sociais, econômicas e políticas de modo irreversível.

Evolução das tecnologias de informação e comunicação

A comunicação, como necessidade primária do ser humano, serve intrinsicamente para integração com outro ser humano desde o surgimento da humanidade. No decorrer da história, há inúmeros relatos da evolução da comunicação humana, principalmente na troca de informação, no registro de fatos, ideias e emoções em cartas, manuscritos, livros e desenhos rupestres. A evolução tecnológica, por sua vez, sempre buscou facilitar e aprimorar a vida das pessoas em várias situações, para sobrevivência, proteção contra o clima ou perigos advindos da natureza, para conforto, para marcar e expressar culturas com seu simbolismo, sua religião e seus costumes (HARARI, 2015).

As tecnologias de comunicação e de transmissão de informação evoluíram, passando das escrituras até os meios digitais, que hoje são usados em larga escala pela sociedade. De acordo com Harari (2015), além das invenções do telefone, da fotografia e do cinema, que impulsionaram a industrialização pelo método fordista no início do século XX, a informação ainda estava engatinhando para alcançar novos patamares, como foi com o próprio telefone, o taquígrafo e o rádio. Nos anos 1930, o cinema foi difundido, e a industrialização dos principais países considerados desenvolvidos se transformou de modo considerável, incluindo o Brasil, com o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Foi inventada a televisão, que surpreendeu o mundo com sua popularidade, além do telefone, do rádio, dos jornais, de revistas e dos livros, que em conjunto são denominados **grande imprensa**.

Saiba mais

O método fordista se refere à produção de produtos básicos em massa com linha de montagem automatizada.

Após a Segunda Guerra Mundial, os militares lançaram uma base de comunicação a distância por computadores, quando se lançou a Arpa e foi evoluindo

todo o aparato computacional (placas-mãe, placas de memória, unidade central de processamento, monitor, acessórios e dispositivos interligados) até chegar no formato conhecido como computador pessoal, interligado por fios telefônicos para troca de informações, dados e códigos a distância.

Nos anos 1980 no Japão, criou-se o celular, que nos anos 2000 tornou-se o meio de comunicação mais popular do mundo, junto com os computadores pessoais, *laptops*, *tablets* e *smartphones.* Toda essa evolução abrange as tecnologias da informação e comunicação (TICs), definidas, conforme Pinheiro (2016), como um conjunto de tecnologias que possibilitam a produção, o acesso e a ampla propagação de informações, que, ao mesmo tempo, possibilitam comunicação entre pessoas, no sentido de serem emissoras e receptoras de modo simultâneo e concomitante. Com a referida evolução tecnológica, surgiram novas invenções, ferramentas e dispositivos, que se propagaram pelo mundo todo, transformando as informações com novas formas de difusão do conhecimento.

As TICs são práticas e utilizadas em variadas áreas, desde a indústria até o comércio e a prestação de serviços, entidades financeiras, educação e agronegócio. Suas aplicações são inúmeras, mas o principal objetivo é proporcionar o acesso à informação e à comunicação de modo automatizado. Nesse aspecto, no conjunto de tecnologias emergentes, incluem-se *softwares* (programas de computadores) e *hardwares* (parte física dos computadores e seus acessórios), a fim de garantir a operacionalização da comunicação. Obviamente, conforme Pacievitch (c2021) observou, as TICs se popularizaram por causa da internet.

As TICs evoluíram, melhoraram e simplificaram várias atividades humanas. Fizeram o princípio da comunicação ultrapassar barreiras e proporcionar, no seu curto período de tempo, a Quarta Revolução Industrial, que foi da informação, robótica e conquista espacial para o patamar de inteligência artificial, nanotecnologia, computação quântica e aprimoramento da exploração espacial. A evolução das TICs beneficiou a humanidade, principalmente em relação à ciência, ao conhecimento e à educação, com compartilhamento de informações de modo surpreendente, por placas de memória de *chips, pendrives*, sistemas assemelhados de gravação de dados, informações e arquivos, até chegar ao que se denomina hoje compartilhamento informacional em nuvem.

Além disso, de acordo com Harari (2015), o desenvolvimento de computadores auxiliou na educação, porque a internet e os dispositivos computacionais possibilitaram a comunicação de pessoas de vários espaços (localização geográfica) e classes sociais diferentes. Difundiu, também, o

acesso a cursos superiores, técnicos, profissionalizantes e livres às pessoas. Diante desse quadro, a tendência é de que as TICs abranjam todas as áreas de automatização da ação humana, o que faz conhecimento, informação, comunicação e educação ultrapassarem fronteiras. Conforme afirma Lira (2003), o conhecimento tornou-se um dos fatores de maior importância para a superação de desigualdades, criação de emprego, agregação de valor e propagação do bem-estar.

Pode-se observar que o desenvolvimento tecnológico é a base do progresso das organizações, o que possibilitou a consolidação da globalização econômica, social, política, científica, cultural e tecnológica. As grandes transformações atuais influenciam a concorrência de grandes corporações transnacionais, a volatilidade e a especulação do mercado financeiro, os deslocamentos sociais, a economia global, os blocos políticos internacionais e as legislações e tratados internacionais que procuram acompanhar tais transformações.

Evolução da internet

A internet surgiu num contexto de Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, quando se desenvolveu a Arpanet, que "[...] foi a primeira rede a ser implementada, em 1969. Mesmo depois de outras redes de computadores terem surgido, ela manteve-se durante praticamente toda a década de setenta do século passado como a mais importante" (ROSA, 2012, documento *on-line*). Nos primórdios da criação da rede, o acesso à Arpanet se limitava a empresas ligadas à defesa militar e às universidades que faziam pesquisas, conforme o interesse dos governos (LAQUEY; RYER, 1994).

A empresa de Bill Gates, a Microsoft, praticamente ocupou todo o espaço do mundo da informática para os usuários em geral de microcomputadores, tendo como sua principal concorrente a Linux:

> A estrutura física da internet é constituída pelo conjunto de computadores que a compõem e pelos meios físicos que os interconectam, como fibras óticas, linhas telefônicas, ondas de rádio etc. A estrutura lógica da internet ou o seu "código" são as inúmeras linguagens que fazem com que as partes físicas possam comunicar-se entre si. Nesta camada, estão incluídos não só os programas de computador, como também protocolos e linguagens compartilhadas entre eles (como o protocolo TCP/IP, base da internet). Aqui se incluem também os sistemas operacionais, como o sistema Microsoft Windows ou o Linux. A estrutura de conteúdo corresponde a tudo aquilo que é transmitido sobre as camadas física e lógica, como um texto, um *e-mail*, uma música, um filme, uma mensagem, uma fotografia etc. (LEMOS, 2005, p. 16).

Para compreender a origem da internet diante de sua estrutura, Castells e Cardoso (2005) afirmam que a Arpanet foi um programa menor, que surgiu de um dos departamentos da agência Arpa, que se chamava Divisão de Técnicas de Processamento de Informação, no ano de 1962. Seu objetivo foi investigar o campo da informática interativa e percorrer uma grande estratégia de expansão no meio interconectado da "grande teia" virtual. Conforme Castells e Cardoso (2005, p. 25):

> Em 1969 os primeiros nós da rede encontravam-se na Universidade da Califórnia em Los Angeles, no SRI (*Stanford Research Institute*), na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, e na Universidade do Utah. Em 1971 havia, no total, 15 nós, a maior parte dos quais eram centros de investigação universitários [...]. Em 1972 teve lugar a primeira demonstração com êxito da Arpanet, durante um Congresso Internacional, em Washington DC.

O grande marco da internet para consolidação e divulgação de novas tecnologias em comunicação entre computadores aconteceu em 1972, em Washington, Estados Unidos, quando foi realizada a primeira Conferência Internacional em Comunicações de Computadores. Na ocasião, foi feita a primeira demonstração de comunicação entre dois computadores conectados (ROSA, 2012). Com essa demonstração, percebeu-se que era possível que as organizações se conectassem para alcançar vantagens e oportunidades das comunicações eletrônicas em redes privadas de comunicação (no caso, a Arpanet). Para isso, interligaram sistemas diferentes de computadores.

A internet cresceu nos institutos de pesquisa e no meio acadêmico, em virtude da ampliação da rede com vários sistemas computacionais diferentes, até que se padronizou o correio eletrônico com o sinal arroba (@). Cientistas e estudantes começaram a utilizá-lo para se comunicar, trocar informações e compartilhar recursos dos computadores. Foi dessa maneira que a internet tomou sua forma própria, tornando-se o maior meio de comunicação global, encurtador de distâncias, entretenimento, entre outras funções que pode assumir com o decorrer do tempo. Para essa interconexão entre várias organizações, em 1983, criou-se o TCP/IP (*transmission control protocol/internet protocol*), que, até hoje, é o protocolo de comunicação usado pelos computadores do mundo todo interligados à grande rede (ERCILIA; GRAEFF, 2008). Contudo, a invenção que possibilitou a popularização da internet em todo o mundo foi a World Wide Web ("www", ou teia de alcance mundial), criada por Tim Berners-Lee em 1990, na Suíça (ROSA, 2012).

Portanto, a computação e a internet se originaram de pequenas conquistas tecnológicas feitas por vários cientistas geniais e brilhantes, que trouxeram

avanços em várias áreas econômicas, sociais, institucionais, organizacionais e públicas, proporcionando facilidades, informação, entretenimento e praticidade no cotidiano. Isso tudo trouxe mudanças na sociedade e no direito, que merecem ser discutidas à parte.

Mudanças na sociedade e no direito com as novas tecnologias

A aplicação de novas tecnologias, ao mesmo tempo que levanta reflexões e debates sobre as relações sociais e jurídicas, proporciona mais eficiência e interação entre o cidadão e o Estado. Em Boston, por exemplo, a prefeitura disponibiliza aos cidadãos o Street Bump, aplicativo capaz de mapear os buracos nas ruas. Em Santander, na Espanha, milhares de sensores espalhados pela cidade são capazes de coletar informações sobre o trânsito, qualidade do ar, iluminação pública e lixeiras. A Austrália, em 2021, começou a testar o uso de ônibus elétricos e paradas inteligentes (com telas *touchscreen* que estimam tempo de espera). Esses são pequenos exemplos do que é possível com a internalização das novas tecnologias: uma aproximação entre o Estado e o cidadão.

Na perspectiva da tecnologia da informação, o direito e o Estado precisam se adequar e se reinventar, seja para acompanhar o avanço tecnológico, seja para se aproximar da sociedade. Os impactos das novas tecnologias repercutem na complexidade do direito, na proteção e na privacidade das pessoas, com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e na investigação/persecução de crimes digitais, com suas devidas penas e coibição de práticas ilícitas que firam bens jurídicos protegidos pela Constituição Federal de 1988 e pelas leis. Outras possibilidades incluem a proteção da propriedade intelectual (direitos digitais, direito industrial e direito de patentes e assemelhados), uso dos recursos dos processos judiciais eletrônicos para resolução de conflitos na Justiça e em processos administrativos nos órgãos públicos, na elaboração e na legitimação de contratos eletrônicos comerciais, bancários, consumeristas e administrativos. Observa-se, também, que a prática de atos criminosos nas redes sociais, como *cyberbullying* e *stalking* obrigou o ordenamento jurídico a criminalizar condutas não previstas originariamente no Código Penal.



Saiba mais

Em agosto de 2018, foi aprovada a Lei nº 13.709, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para proporcionar segurança jurídica na padronização de normas e práticas em relação aos dados pessoais de todo cidadão no Brasil. A lei define o que são dados pessoais, que cuidados devem ser tomados e admite regulação por normas administrativas dos órgãos públicos no país.

O avanço das tecnologias de informação e comunicação exige ajustes no mundo jurídico, o que requer atualização, engajamento e busca de soluções inovadoras diante de problemas complexos. A privacidade de crianças e adolescentes nas redes sociais, que podem ficar expostas a crimes virtuais, é um exemplo desses problemas. Além disso, a tecnologia mudou a dinâmica entre escola e família. No mundo do direito, isso pode compreender o direito digital, o direito civil na subárea de direito de família e, também, o direito educacional.

Na legislação brasileira e nos tratados internacionais, há regras possíveis para normatização e regulamentação, mas que não são suficientes para toda a realidade que abarca as TICs. Percebe-se, diante disso, a necessidade de governantes, legisladores, juristas e profissionais de TICs (cientistas da computação, engenheiros de computação, analistas de sistemas, programadores e demais profissionais da área) buscarem consenso e proposições de normas legais e regulamentares para resolverem demandas da sociedade competitiva e complexa. Além disso, a doutrina jurídica e a jurisprudência precisam focar as questões das novas tecnologias, com seu objeto, seja de estudo ou de julgado, no sentido de acompanhar as inovações tecnológicas no dia a dia e fixar parâmetros, critérios e princípios sobre como lidar com tais problemas advindos das TICs.

No entanto, não é somente na legislação que as novas tecnologias estão interferindo no mundo jurídico. As atividades antes desenvolvidas por servidores estão aos poucos sendo substituídas por robôs. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2016, foi apresentado ao mundo o Ross, a máquina (robô). Tendo por base a plataforma do Watson (computador criado em 2006 com a capacidade de mudar seu comportamento diante de uma situação — uma *machine learning*), ele consegue criar teorias, não somente expor resultados com base em fatos passados. No Brasil, em 2017, foi apresentado na Fenalaw o ELI (*Enhanced Legal Inteligence*), primeiro robô advogado do país, com capacidade de processar 500 gigabytes, ou um milhão de livros, em apenas um segundo, tendo, também, inteligência artificial. Na mesma linha,

o Supremo Tribunal Federal, em 2018, anunciou a criação do Victor, que teve como função inicial "[...] ler todos os recursos extraordinários que sobem para o STF e identificar quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral" (BRASIL, 2018, documento *on-line*). Foi lançado no mesmo ano, pelo Superior Tribunal de Justiça, o projeto-piloto de uso da inteligência artificial (hoje sabemos que se trata do Sócrates) para identificação de temas jurídicos nos processos, separação de processos com controvérsia idêntica e localização de processos em que sejam aplicáveis os mesmos precedentes do tribunal (AGAS, 2018). Outro exemplo é o da Estônia, que, com a criação da identidade digital, vem investindo fortemente no *blockchain,* que já permite aos estonianos votar, editar formulários, solicitar benefícios sociais, acessar serviços bancários, transporte público, tudo sem a necessidade de cartões bancários ou de ônibus (TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2016).

Saiba mais

A internet das coisas (*internet of things* — IoT) é um conjunto de bens (objetos físicos) conectados à internet, por meio de sensores, e que podem ser controlados por essa rede. Sua aplicação aos bens públicos, carros, motos, caminhões, etc., ou que estão a serviço da administração (como veículos locados, por exemplo), pode gerar uma enormidade de dados, passíveis de conferência não só pela administração, mas pelo próprio cidadão, como uma espécie de controle popular (SANTANNA, 2019).

É possível verificar que as tecnologias de informação e comunicação têm modificado o comportamento não apenas da sociedade, mas também do Estado e do direito. Diversas leis têm sido publicadas com o objetivo de regular o uso dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade dos cidadãos. É por essa razão que as novas ferramentas tecnoinformacionais, assim como podem trazer diversos benefícios, também podem causar discriminação pelo uso indevido de dados, expondo, consequentemente, a privacidade. Assim é que o direito desempenha um papel fundamental nesse novo ambiente tecnológico: regulando e protegendo a sociedade.

Referências

AGAS. *STJ entra na era da inteligência artificial*. Porto Alegre: Agas, 2018. Disponível em: https://www.agas.com.br/site/default.asp?TroncoID=708180&SecaoID=648484&SubsecaoID=0&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=616273. Acesso em: 2 maio 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Inteligência artificial vai agilizar a tramitação de processos no STF*. Brasília, DF: STF, 2018. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038. Acesso em: 2 maio 2021.

CASTELLS, M.; CARDOSO, G. *A sociedade em rede*: do conhecimento à ação política. Belém: Imprensa Nacional, 2005.

ERCILIA, M.; GRAEFF, A. *A internet*. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2008.

HARARI, Y. N. *Sapiens*: uma breve história da humanidade. São Paulo: L&PM, 2015.

HOBSBAWM, E. *Da revolução industrial inglesa ao imperialismo*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

LAQUEY, T.; RYER, J. C. *O manual da internet*: um guia introdutório para acesso às redes globais. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

LEMOS, R. *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

LIRA, W. S. Impactos da tecnologia de informação nas organizações. *RECADM*, v. 2, n. 2, 2003. Disponível em: http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/435. Acesso em: 31 mar. 2021.

PACIEVITCH, T. *Tecnologia da informação e comunicação*. [*S. l.*]: InfoEscola, c2021. Disponível em: https://www.infoescola.com/informatica/tecnologia-da-informacao--e-comunicacao/. Acesso em: 1 abr. 2021.

PINHEIRO, P. P. *Direito digital*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

ROSA, A. M. As origens históricas da internet: uma comparação com a origem dos meios clássicos de comunicação ponto a ponto. *Estudos em Comunicação*, v. 1, n. 11, p. 95-123, 2012. Disponível em: http://www.ec.ubi.pt/ec/11/pdf/EC11-2012Mai.pdf. Acesso em: 30 mar. 2021.

SANTANNA, G. S. *Do patrimonialismo à sociedade da informação*: proposições para a implantação da administração pública eletrônica (e-administração) no Brasil. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2019. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/9048/Gustavo%20da%20Silva%20Santanna_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 maio 2021.

SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2019.

TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. *Blockchain revolution*: como a tecnologia por trás do bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: Senai-SP, 2016.

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
1
V.1 | 2023

Parte 2

Direitos Fundamentais na era da Informática

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Direitos fundamentais na era da informática

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Definir o acesso à internet e sua neutralidade como direito humano fundamental.
- Explicar a relação entre liberdade de expressão e *fake news*.
- Reconhecer os limites dos direitos autorais e da propriedade intelectual na internet.

Introdução

O comportamento social foi alterado significativamente nas últimas décadas, quando o acesso à internet se tornou cada vez mais fácil, com o desenvolvimento das tecnologias e a criação e popularização de *smartphones*, por exemplo. O acesso à rede mundial de computadores fez a área do direito precisar se atualizar ao novo mundo, que passou a ser pautado no ciberespaço, uma reprodução genuína da vida cotidiana através de telas, com a rápida troca de informações.

O acesso à internet, pautado no princípio da neutralidade, tornou-se direito fundamental. Com isso, o balizamento entre outros direitos fundamentais passou a ser matéria corriqueira nos tribunais brasileiros. Além disso, a liberdade de expressão, extremamente salvaguardada pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, [2020]), precisou passar por uma reanálise quando as *fake news* começaram a interferir diretamente em processos democráticos, como as eleições, e em questões

cotidianas, como a proteção da imagem e da voz, da honra e da personalidade em um espaço virtual. Por fim, os direitos autorais e a propriedade intelectual, antes tão esclarecidos pelos limites previstos na legislação pátria, começaram a criar novas situações e colocar em pauta a atualização legal quanto à matéria.

Neste capítulo, você vai conferir o que é acesso à internet e sua neutralidade como direito humano fundamental. Além disso, vai visualizar a relação entre a liberdade de expressão e as *fake news*. Por fim, você vai conhecer quais são os limites dos direitos autorais e a propriedade intelectual na era digital.

Acesso à internet como um direito humano fundamental

O direito à liberdade foi conquistado ao longo das décadas pela sociedade, principalmente por meio da construção de estados democráticos, sendo que, no Brasil, é colocado como direito fundamental de primeira dimensão. O direito à liberdade de expressão e de comunicação é baseado na liberdade em si, nos direitos civis e políticos e na cidadania (SOUZA; SILVEIRA, 2018). Com o advento da internet, percebeu-se que informações no espaço virtual começaram a ser dotadas de valores especiais por cada pessoa, uma vez que o acesso à internet passou a ser sinônimo de reprodução digital do mundo real. Isso ocorreu em virtude de a pessoa humana ser disposta tal qual "[...] um ser de eminente dignidade, caracterizado por sua razão e por sua liberdade. Esse reconhecimento exige respeito e um tratamento do homem como sujeito, cuja independência e liberdade têm de ser garantidas na vida social" (PECES-BARBA, 1993, p. 61).

No estado democrático de direito, o acesso à informação é um meio fundamental para a expressão da liberdade, e a possibilidade do acesso às informações na internet deve se dar de modo aberto e livre. O Estado não pode representar uma ameaça ao direito à informação, agindo de forma autoritária e restringindo direitos. "O poder de polícia do Estado que ameaça a liberdade em suas diversas modalidade é o mesmo que quebra constantemente a barreira da vida privada dos cidadãos" (SOUZA; SILVEIRA, 2018, p. 4). Neste sentido, Silveira (2006, p. 11) aponta que:

> Como vivemos em uma sociedade pluralista, formada por diversas crenças, valores e concepções de vida, definir direitos de forma universal com referência a valores que pesam mais que outros destrói com qualquer possibilidade de afirmação do indivíduo enquanto ser dotado de liberdade de escolha, pois vincula seus direitos com o senso geral da sociedade sobre uma hierarquia de valores pré-fixada. Cada pessoa, assim, tem direito de desenvolver-se sem a interferência da sociedade.

Desse modo, o acesso à internet no Brasil, além de garantir a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, diante do que determina a Carta Magna de 1988, é compreendido como direito fundamental. Nesse sentido, em 2014, o Brasil promulgou a Lei nº 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil (BRASIL, [2018]). Essa disposição jurídica traz, em seu art. 3º, os princípios que norteiam a utilização da rede mundial de computadores:

> Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
> I – garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
> II – proteção da privacidade;
> III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
> IV – preservação e garantia da neutralidade de rede;
> V – preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
> VI – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
> VII – preservação da natureza participativa da rede;
> VIII – liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.
> Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (BRASIL, [2018], documento *on-line*).

No ordenamento jurídico pátrio, os princípios têm a função de direcionar as atividades dos poderes executivo, legislativo e jurisdicional do Estado, atuando como paradigmas para a sociedade civil de forma global (SOUZA; SILVEIRA, 2018). Logo, conclui-se que o Marco Civil da Internet intenciona ser uma carta de direitos às tecnologias de informação e comunicação. Assim, os direitos declarados na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, [2020]), que garantem a dignidade humana pela Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (BRASIL, [2018]), são reafirmados, como a liberdade de expressão, a personalidade e a proteção à intimidade e à privacidade, o exercício da cidadania e a defesa do direito do consumidor. Além disso, o Marco Civil da Internet procura promover, de acordo com a disposição do art. 4º, a inclusão social e digital, orientando o legislador a formular políticas públicas e a fornecer a reinterpretação das leis vigentes (BRASIL, [2018]). Isso ocorre, por exemplo, com a ????, que, em seu art. 154, dispõe sobre o compartilhamento de redes de telecomunicações, que pode ser interpretado à luz do Marco Civil da Internet, visando à ampliação do acesso de todos à rede mundial de computadores. Em contrapartida, as leis

que determinem obstáculos à aplicação desses princípios devem receber uma nova interpretação, de acordo com a Lei nº 12.965/2014 (SOUZA; SILVEIRA, 2018).

Diante disso, a internet se revela como um direito fundamental, uma vez que se tornou essencial para o desenvolvimento da cidadania, o acesso à informação, a liberdade de expressão, o direito à cultura, entre tantos outros meandros. Segundo Bobbio (2004, p. 53), "[...] o desenvolvimento da técnica, as transformações das condições socioeconômicas, a ampliação do conhecimento e a intensificação dos meios de comunicação poderão [...] criar condições para o nascimento de novos carecimentos e novas demandas de liberdade e poderes". Nesse sentido, a Carta Maior do Brasil traz, no que tange ao Título II, inúmeros prelúdios de direitos fundamentais, alcançando direitos individuais e coletivos sem utilizar uma numeração exaustiva. Conforme se observa no parágrafo 2º do art. 5º, a cláusula de abertura ao catálogo possibilita a inclusão de outros direitos resultantes da estrutura e dos princípios adotados, bem como dos tratados e convenções internacionais e dos direitos fundamentais conjecturados fora do Título II ao longo da Constituição Federal vigente (SOUZA; SILVEIRA, 2018).

Um direito é tido como formalmente fundamental quando detém essa qualificação por meio de ordem expressa do legislador-constituinte. Já a condição de direito materialmente fundamental depende, sobretudo, de que tal proteção seja parte integrante da Constituição material, em relação à essência e à substância que exigem tal reconhecimento (SARLET, 2007). Nesse sentido:

> Busca-se a equivalência do direito àqueles tidos como formalmente fundamentais, ou seja, sua relevância, a substância e conteúdo. Essa relevância de acesso à internet se revela seja no direito prestacional como no de defesa. A liberdade que subsidia o direito à livre expressão e à liberdade informativa está essencialmente ligada à comunicação entre as pessoas e ao intercâmbio de informações (SOUZA; SILVEIRA, 2018, p. 8).

Assim como a sociedade está em constante modificação, o direito também deve estar, para que questões cotidianas possam ser tratadas, analisadas e solucionadas pela prestação jurisdicional. No ato da promulgação da Constituição de 1988, a internet ainda engatinhava para a popularização no Brasil, porém esse cenário se alterou muito rápido. Logo, a partir desse contexto, percebe-se como os direitos fundamentais passam por constantes alterações, em um permanente processo de formação conforme as necessidades sociais. Sem dúvida, a rede mundial de computadores detém um lugar de destaque no rol de direitos fundamentais, no sentido de que abre oportunidades para as liberdades de expressão e comunicação, constituindo uma verdadeira manifes-

tação de direitos políticos e civis e possibilitando a solidificação da cidadania por meio "[...] de uma democracia participativa à luz do pluralismo informativo e do livre acesso à circulação de informação" (SOUZA; SILVEIRA, 2018, p. 8).

O direito fundamental de acesso à internet representa um mandamento de proibição dirigido ao Estado e, igualmente, aos particulares, para que fiquem impedidos de restringir, de maneira desproporcional e injustificada, o acesso das pessoas à internet. Outra questão importante é o destaque à igualdade material, que pode ser inserida no direito de conexão, a fim de promover a liberdade de acesso a todas as pessoas. Por esse motivo, as pessoas que têm limitações para o acesso à rede mundial de computadores, sejam físicas, de manuseio ou econômicas, têm o poder de exigir do Estado a prestação dessa atividade para diminuir a desigualdade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2016, cerca de 63 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet, e 37,8% da população desconhecia o uso da rede mundial de computadores (SOUZA; SILVEIRA, 2018).

No Brasil, os principais temas trazidos pelo Marco Civil da Internet foram a privacidade, a neutralidade da rede e a inimputabilidade da rede, princípios que garantem os direitos e as liberdades democráticos dos internautas em relação às ações abusivas do Estado, de entidades internacionais e de empresas prestadoras de serviços (SOUZA; SILVEIRA, 2018).

A neutralidade, princípio previsto no art. 9º da Lei nº 12.965, de 2014 (BRASIL, [2018]), indica que todos os dados que trafegam na rede têm de receber igual tratamento das empresas provedoras de acesso, sem que haja diferenciação em relação à origem, ao destino, ao serviço, ao conteúdo ou ao dispositivo. Nesse sentido, Hartmann ([2007], p. 27) salienta que:

> Como restrições entendemos tanto o impedimento físico de acesso, como o controle deste, na forma de limitação dos *sites* que poderão ser visualizados, bem como na forma de censura. O acesso deve ser inicialmente livre, privilegiando a possibilidade indiscriminada de troca de informações, tanto aquelas que o indivíduo recebe — guardando-se aí certa similaridade com o direito à informação — como aquelas que envia — existindo então maior proximidade com o direito à liberdade de expressão.

Nesse sentido, a neutralidade é o núcleo essencial do direito fundamental do acesso à internet. Desse modo, restrições, reduções ou limitações do conteúdo na rede mundial de computadores implicam prejuízo de tal direito. Muito embora a Constituição Federal de 1988 não contemple de forma expressa a proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, é evidente que a proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais deriva do modelo de garantia utilizado pelo legislador-constituinte. Assim, o princípio

de proteção ao núcleo essencial do direito fundamental visa a estabelecer um "[...] limite para a limitação dos direitos fundamentais" (SOUZA; SILVEIRA, 2018, p. 11). Portanto, o princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais se destina a obstar o esvaziamento da temática do direito fundamental de restrições descabidas e desproporcionais. De acordo com Souza e Silveira (2018, p. 12):

> O legislador não pode [...], uma vez concretizado determinado direito social no plano da legislação infraconstitucional, ainda que com efeitos meramente futurológicos, retroagir e, mediante uma supressão ou mesmo relativização, afetar o núcleo essencial legislativamente concretizado de determinado direito fundamental. É em primeira linha o núcleo essencial dos direitos sociais que vincula o Poder Público no âmbito de uma proteção contra o retrocesso e que, portanto, representa aquilo que efetivamente se encontra protegido.

Nesse sentido, a neutralidade da internet está assentada de acordo com a instrução da Organização das Nações Unidas (ONU), que aponta o acesso à internet como um direito humano. O Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pelo Brasil em 1992, estabelece, no 2º parágrafo do art. 19, que "[...] toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de condições de fronteiras" (BEZERRA; WALTZ, 2014, p. 167). A ONU compreende que restrições e bloqueios à internet constituem uma violação do art. 19, ainda que devido a infrações de direitos autorais (BEZERRA; WALTZ, 2014).

O âmago da neutralidade está vinculado com condutas aceitáveis e inaceitáveis por parte dos provedores de conexão, sendo impedidos "[...] a discriminação e o bloqueio de aplicativos, a priorização de aplicativos, vedada a degradação do tráfego na rede e obrigatória a transparência aos usuários sobre as medidas de gerenciamento da rede" (SOUZA; SILVEIRA, 2018, p. 13). Assim, todo conteúdo que esteja na internet deve ser tratado de forma isonômica, de acordo com o princípio da neutralidade (SOUZA; SILVEIRA, 2018). Ramos (2014, p. 165) explica a neutralidade da seguinte forma:

> (i) o princípio da neutralidade da rede impõe a provedores de acesso a obrigação de não bloquear o acesso de usuários a determinados *sites* e aplicações, sendo também vedado aos provedores de acesso arbitrariamente reduzir a velocidade ou dificultar o acesso a aplicações específicas; (ii) a neutralidade da rede impede a cobrança diferenciada para acesso a determinados conteúdos e aplicações, sendo livre a cobrança de tarifas diferenciadas conforme a velocidade de acesso ou volume de banda utilizada; e (iii) os provedores de acesso devem manter práticas transparentes e razoáveis a respeito de seus padrões técnicos de gerenciamento de tráfego.

Desse modo, ações que atentem contra a neutralidade são passíveis de atingir o núcleo essencial do direito fundamental à internet. A neutralidade não implica prejuízo para os provedores de serviços ou para o Estado, porém o bloqueio à neutralidade provoca prejuízos aos cidadãos, passando a limitar o exercício de inúmeros outros direitos fundamentais, sobretudo o da liberdade (SOUZA; SILVEIRA, 2018).



Fique atento

Observe o que Ávila e Woloszyn (2017, p. 196) afirmam:

A preocupação legítima do legislador infraconstitucional em preencher as lacunas deixadas pela Lei Maior, adaptando-as ao ambiente social, por vezes, implica na deformidade e desvirtuamento da norma, como no caso do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.296 de 1996 que trata da interceptação telefônica. De modo semelhante, pode-se afirmar que a Lei Complementar nº 105 de 2001 e a Lei nº 12.965 de 2014, conhecida como o Marco Civil da Internet, e tida como uma lei de princípios gerais, não correspondem à exigência de proteção do sigilo de dados e das comunicações na *web*, particularmente, em relação a práticas adotadas pelas empresas que mantêm o armazenamento de dados e informações fora do território brasileiro e frente aos crimes cibernéticos. Ao mesmo tempo em que o fundamento da inviolabilidade constitucional do sigilo das comunicações está em assegurar sua não manipulação pelo Estado, de modo a transformar a quebra de sigilo em um instrumento de devassa indiscriminada na intimidade das pessoas, o Marco Civil da Internet permite, ao Estado, a possibilidade praticamente ilimitada da quebra de sigilo em toda e qualquer comunicação em rede, mesmo que existam cláusulas de excepcionalidade.

Liberdade de expressão e *fake news*

No estado democrático, os direitos fundamentais de liberdade são reconhecidos por meio da participação política, guiada por uma determinação de vontade autônoma de cada indivíduo. A soberania é o exercício da vontade geral, e somente esta tem a possibilidade de dirigir as forças do Estado, segundo a finalidade de sua instituição, isto é, do bem comum (OLIVEIRA, 2021).

A Constituição Federal de 1988, ao ser promulgada, apresentou-se bastante preocupada com o direito à liberdade de expressão e com a vedação à censura, em função de sua edificação e proclamação serem resultado de um processo de redemocratização brasileira, após 21 anos de ditadura militar no país. Dessa forma, a liberdade de expressão é garantida pela Carta Magna, em particular no que dizem os incisos IV e IX do art. 5º, no rol de direitos e garantias fundamentais. A preocupação por parte da Assembleia Constituinte foi tão expressiva que atribuiu à liberdade de expressão o *status* de cláusula pétrea. Ainda, no que tange aos meios de controle e restrição dessa liberdade,

a Carta Maior tem providências nos arts. 220 e 221, fixando impedimentos legislativos, conforme é possível verificar nos parágrafos 1º e 3º do art. 220, que proíbe expressamente a censura e determina princípios diretivos que devem guiar a produção da imprensa, matéria prevista nos parágrafos 4º, 5º e 6º do art. 220, combinados com o artigo 221 (BRASIL, [2020]). Segundo Sarlet (2019, p. 1209–1210):

> Na perspectiva do Direito, um dos principais desafios segue sendo o de buscar assegurar um equilíbrio entre o exercício pleno da liberdade de expressão nas suas mais diversas dimensões, por um lado, e a necessária proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade, por outro, mas também o de operar como instrumento para a afirmação, do pondo de vista transindividual, de um ambiente com níveis satisfatórios de tolerância e reconhecimento. Sem isso, o próprio Estado Democrático de Direito, necessariamente livre, plural e igualitário, estará em risco.

Em setembro de 2003, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou um dos mais emblemáticos casos relacionados com os limites da liberdade de expressão: o Caso Ellwanger. Por 8 votos contra 3, o STF condenou Siegfried Ellwanger pela prática de crime de racismo, por meio do *habeas corpus* 82.424/RS. Ao longo dos anos, Ellwanger se dedicou à publicação de obras notoriamente antissemitas, bem como à denegação da existência fática do Holocausto, quando publicou o livro *Holocausto — judeu ou alemão? Nos bastidores da mentira do século* (BRASIL, 2003). Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello, em seu voto, destacou que:

> A prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo de incidência, não constitui meio que possa legitimar a exteriorização de propósitos criminosos, especialmente quando as expressões de ódio racial — veiculadas com evidente superação dos limites da crítica política ou da opinião histórica [perpassam], de modo inaceitável, valores tutelados pela própria ordem constitucional dos limites da crítica política ou da opinião histórica [ultrapassam], de modo inaceitável, valores tutelados pela própria ordem constitucional (BRASIL, 2003, documento *on-line*).

Portanto, a liberdade de expressão não pode ser utilizada com o objetivo de prospectar práticas criminosas, que estimulem situações de intolerância e ódio e, mais atualmente, que disseminem notícias inverídicas, que se alastram como uma praga por meio da rede mundial de computadores, podendo afetar processos democráticos expressivos, como os resultados eleitorais.

Desse modo, o julgado de 2003 da Corte Suprema do Brasil se faz atual, visto que os ministros manifestaram que a liberdade de expressão não é

um direito absoluto e, quando está em conflitos, como, por exemplo, com a dignidade da pessoa humana, não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral e falso, na medida em que "[...] as liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observando os limites da própria Constituição Federal (art. 5º, §2º, primeira parte)" (BRASIL, 2003, documento *on-line*).

Dessa forma, o que se retira é que o entendimento do STF é de que a liberdade de expressão não é excluída ou cristalizada dos cidadãos e, nesse contexto, dos usuários da internet, porém é absolutamente necessário revogá-la quando está em conflito com outro direito fundamental, não estabelecendo uma hierarquia entre direitos fundamentais. Trata-se, unicamente, de abrir margem ao exame particular de cada caso, à luz da dignidade da pessoa humana e de outros preceitos trazidos pela Carta Magna (BRASIL, 2003).

Nesse contexto, o fenômeno das *fake news* aumentou de forma alarmante com o crescimento do acesso à internet e com a propagação e a popularização das redes sociais. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XIV, determina o direito fundamental do acesso à informação (BRASIL, [2020]). Todavia, com a internet, percebe-se um expressivo aumento da propagação de informações na sociedade e, como consequência, do alcance à informação, tornando o acesso à internet um direito fundamental, pautado pelo princípio da neutralidade. Logo, a difusão de informações não verdadeiras aparece de forma conjunta com o surgimento da comunicação humana. Contudo, na era da informática, o impacto das informações verídicas ou inverídicas toma proporções colossais. Conforme Nohara (2020, p. 75):

> O fenômeno das *fake news* não é recente. Apesar de situarem seu início na Antiguidade Clássica, quando se desenvolveram a política e a retórica, ainda assim se pode especular que ele acompanhe o ser humano desde o momento que este começa a se comunicar, podendo, portanto, divulgar fatos verdadeiros ou disseminar deliberadamente notícias que são falsas para obtenção de algum benefício.

Nesse sentido, muito embora a propagação de notícias falsas exista há muitos anos, em 2016, as *fake news* passaram a ganhar maior notoriedade, tanto nos noticiários quanto nas questões sociais e, claro, nas páginas da internet. Isso se deu principalmente pelo fato de que, naquele ano, dois eventos sumariamente importantes ocorriam no mundo e eram impulsionados pelas mais diferentes notícias: as eleições presidenciais norte-americanas e o referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). Oliveira e Gomes (2019, p. 112) resume esses eventos da seguinte forma:

> Papa Francisco apoiou Donald Trump; o presidente norte-americano Barak Obama fundou o Estado Islâmico; a primeira-dama, Michele Obama, é um homem; Barack Obama não é norte-americano; a permanência da Grã-Bretanha na União Europa custa 350 milhões de libras por semana aos cofres públicos, e esse recurso seria destinado ao serviço público de saúde com a saída do bloco. Todos são exemplos de notícias falsas que pautaram [as eleições presidenciais estadunidenses e o BREXIT] [...] a temática para o debate público.

O fenômeno das *fake news* após 2016 é a ponta do iceberg de um método complexo de desinformação e radicalização política, em que antigos riscos à democracia obtêm uma nova roupagem, dado o sistema tecnológico em que os mecanismos estão pautados. Segundo Oliveira e Gomes (2019, p. 94), não é possível considerar as adversidades democráticas atuais sem confrontar dilemas contraditórios cedidos pelo avanço da tecnologia das "[...] sociedades hiperconectadas que transformou os modos de vida, da interação social e da construção de debates políticos". Para os autores (2019, p. 95):

> A insegurança gerada pela desinformação constitui por si só uma ameaça à democracia e à pluralidade política. A situação se agrava no contexto mundial em que a reascensão de ideais ultraconservadores e segregacionistas vem ganhando ares de normalidade e aponta-se que a difusão de notícias falsas tem servido especialmente à sua propagação, embora sejam utilizadas por grupos de diferentes espectros políticos.

Desse modo, a ideia de *fake news* passa a ser utilizada no sentido de desqualificar informações não verdadeiras, o que sempre fez parte da dinâmica do jornalismo e da liberdade de expressão. Conforme Oliveira e Gomes (2019, p. 95–96):

> A eleição dos EUA de 2016, a decisão pelo Brexit em 2016, a força da candidata de extrema direita Marie Le Pen na França em 2017, as eleições presidenciais no Quênia de 2017, [as eleições presidenciais no Brasil em 2018], são eventos que alertam para o potencial poder das campanhas de desinformação.

Esses são exemplos concretos de como a criação e a propagação de uma notícia não verificável e que, logicamente, pode não ser confiável é uma violação ao direito fundamental da liberdade de expressão e de informação, causando uma destruição coletiva, uma vez que a informação é imprescindível para a formação da opinião pública, responsável por guiar o exercício das liberdades públicas. No mesmo sentido, é interessante observar que a doutrina trabalha com a liberdade de expressão ainda de modo clássico, ou seja, aquela concebida pela ideia das revoluções liberais, que compreende

a liberdade de expressão como defesa contra as arbitrariedades do Estado. Logo, em tempos de *fake news*, o desrespeito à liberdade de expressão não é praticado pelo Estado, por meio da censura, mas sim por agentes privados, os quais abusam desenfreadamente dessa liberdade (OLIVEIRA; GOMES, 2019).

No Brasil, o STF, com o objetivo de combater as *fake news* durante o período pré-eleitoral de 2018, realizou, em 2017, o Seminário "Internet e Democracia", no qual reuniu especialistas para discutir as questões vinculadas com a propagação de notícias inverídicas e os impactos em relação aos resultados das eleições. Além disso, o Tribunal criou, por meio da Portaria TSE 949, o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições (CCITE), além de realizar campanhas internas e externas de divulgação de informação verdadeira, em parceira com agências de checagem de fatos e verificação de informação, como o Projeto Comprova, Fato ou Fake, Aos Fatos, Agência Lupa e Sala de Democracia Digital da Fundação Getúlio Vargas. Todas essas medidas foram indicadas como positivas pelo Relatório Preliminar da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OLIVEIRA; GOMES, 2019).

No âmbito legislativo, o Brasil avançou no sentido de manter o equilíbrio entre liberdade de expressão e *fake news*, embora seja possível afirmar que não de maneira suficiente para o enfrentamento da questão. A proteção da privacidade e dos dados pessoais é um princípio que disciplina o uso da internet, conforme estabelecido no art. 3º da Lei nº 12.965, de 2014. Destaca-se, ainda, a Lei nº 13.704, de 8 de agosto de 2018, que dispõe sobre a proteção de dados (OLIVEIRA; GOMES, 2019).

Assim, por meio do que vem ocorrendo nacional e internacionalmente, percebe-se que a proliferação de notícias falsas e a propagação da desinformação impactam o processo eleitoral, muito embora inexistam dados empíricos que demonstrem o quanto as *fake news* foram decisivas para os resultados eleitorais no Brasil em 2018. Além disso, apesar de a atuação do STF ter sido interessante, pois criou uma série de novos projetos, não foi suficiente para o enfrentamento das *fake news* (OLIVEIRA; GOMES, 2019).

Com as dimensões das balizas entre a liberdade de expressão e as notícias falsas, constantemente serão demandados maiores esforços, de modo a interdisciplinar a manutenção e a edificação dos pilares democráticos na era digital, perante os quais a confiança e a informação são conjecturas fundamentais.



Saiba mais

Um estudo visou a construir uma cartografia da expressão *fake news* em um recorte temporal, em que foram identificadas irrupções no Brasil entre os anos de 2017 e 2018, anos em que o país vivenciou os períodos pré-eleitoral e eleitoral, tendo as *fake news* como técnica no conjunto de iniciativas utilizadas pelos candidatos e apoiadores para pautar o debate político, conforme destacado por Maíra Moraes Vitorino e David Renault, no artigo "A irrupção das *fake news* no Brasil: uma cartografia de expressão".

Direitos autorais e propriedade intelectual na internet

Os direitos autorais e a propriedade intelectual podem ser visualizados em quase todas as atividades cotidianas, como produções artísticas, culturais ou científicas, ou mesmo industriais, como os modelos de utilidade e as invenções. Esses direitos incidem sobre as criações humanas, de caráter estético ou utilitário, direcionadas à sensibilização e à transmissão de conhecimentos, bem como à satisfação dos interesses materiais do ser humano (BITTAR, 2015). Para Gandelman (1997, p. 26), o direito autoral pode ser definido como "[...] um dos ramos da ciência jurídica que, desde os seus primórdios, e até na atualidade, sempre foi e é controvertido, pois lida basicamente com a imaterialidade característica da propriedade intelectual". Essa complexidade se intensificou com o desenvolvimento tecnológico, na medida em que proporcionou uma ampliação das possibilidades de criação e divulgação das obras intelectuais, sobretudo com o auxílio da internet (TENÓRIO FILHO; MALLMANN, 2017).

Em 1998, o legislador brasileiro publicou a denominada Lei dos Direitos Autorais (LDA), Lei nº 9.610 (BRASIL, [2019]), que passou a disciplinar e proteger as criações intelectuais e, claramente, os direitos autorais e da propriedade intelectual. Dessa forma, para além da legislação nacional, o Brasil, principalmente por meio do desenvolvimento dos meios tecnológicos de comunicação, passou a ser signatário de uma série de tratados internacionais, como: Convenção da União de Berna de 1886, Convenção Universal da União de Paris de 1971 e Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (Trips) da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais de 1994 (GANDELMAN, 1997).

No que tange aos direitos autorais e conexos, os regimes jurídicos são compostos por normativas positivas e negativas. Assim, a Lei dispõe de previsões de limites aos direitos autorais, devendo ser conciliado o uso destes de maneira

coerente aos interesses coletivos (CONRADO, 2013). Portanto, é permitida a explanação relativa ao que impede que o direito do autor tenha caráter absoluto.

A LDA traz, em seu Capítulo IV, o título "Das Limitações aos Direitos Autorais", em que tais limites estão dispostos entre os arts. 46 e 48 (BRASIL, [2019]). A redação do art. 46 sofre críticas quanto à sua aplicabilidade no âmbito jurídico contemporâneo, visto que a ideia de direito autoral acaba por se remodelar com o advento da internet e o crescimento exponencial do uso de redes sociais, aplicativos de *streaming*, páginas de reprodução de vídeos, entre tantos outros itens que fazem parte do cotidiano das pessoas após a ampliação das redes de comunicação, com especial destaque para o entendimento do acesso à internet como direito fundamental.

Na atual redação, casos concretos acabam sendo cuidados pelos tribunais de maneira extensiva, uma vez que já não se faz suficiente a aplicação do art. 46 da LDA, visto que se passaram mais de 20 anos da entrada em vigor da referida lei.

Os limites intrínsecos fazem parte da LDA, ao passo que os limites extrínsecos advêm dos demais textos legislativos da ordem nacional, como é o caso da Constituição Federal de 1988 (ASCENSÃO, 2012). Nesse sentido, a LDA (BRASIL, [2019], documento *on-line*), indica como limites ao direito do autor:

> Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
> I – a reprodução:
> a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
> b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
> c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
> d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;
> II – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
> III – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
> IV – o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
> V – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

> VI – a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;
> VII – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;
> VIII – a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Logo, é possível extrair da LDA que os limites não visam a restringir os direitos do autor, uma vez que eles já têm prazo definitivo de duração previsto em lei, tampouco procuram depreciar o âmbito da proteção das obras autorais e de propriedade intelectual, mas têm por alcance as obras que são protegidas e que, por uso de regra especial, normalmente vedadas, seriam de livre utilização (RODRIGUES, 2014). Desse modo, percebe-se que certas obras protegidas estão excluídas dos direitos autorais, contemplando situações em que é permitido o uso livre da obra, seja pelo fato de não estarem protegidas pela legislação em vigor no Brasil, seja porque passaram a caber em domínio público (BITTAR, 2015).

Em relação às limitações dos direitos autorais, Bittar (2015, p. 92) afirma que:

> [...] exigências da sociedade impõem outras limitações aos direitos autorais. Assim, da vida pública decorrem as limitações concernentes à censura e ao controle de comunicações. De ordem didática são as relativas a coletâneas e antologias. De cunho científico, as citações (para ilustração do pensamento ou reforço) e as críticas (para divulgação de ideias e de ciência). Outras têm sido incluídas sempre em função dos mesmos interesses, em nível de exigências detectadas em cada país (entre nós, a censura foi extinta, uma vez incabível na democracia).

Ainda quanto aos limites dos direitos autorais, na visão de Ascensão (2012, p. 45):

> A diferença estaria no seguinte: a liberdade pode restringir-se ao mero aproveitamento dos espaços livres. Pensemos na liberdade de locomoção: todos a temos, mas isso não significa que possamos penetrar em todos os espaços. Se encontramos um terreno cercado por um muro, não o podemos ultrapassar. Pelo contrário, quando há um direito subjetivo podemos exigir que seja dada entrada. Analogamente se passa no que respeita aos limites ao direito de autor. Se são meras liberdades, só se aplicam enquanto não forem levantados impedimentos pelo titular. Pelo contrário, se forem direitos pode-se exigir juridicamente que a utilização da obra em causa seja facultada.

Contudo, ao considerar os novos espaços de propagação e publicação de materiais autorais, o denominado ciberespaço, procura-se estabelecer um

equilíbrio entre a proteção dos direitos autorias e a liberdade do usuário no espaço virtual, visando à harmonia quando da imposição de limites e exceções (WACHOWICZ; WINTER, [2011]).

Em virtude da modificação do comportamento da ideia de direito autoral com o advento da ampliação do uso da internet, com especial alicerce no Marco Civil da Internet, o movimento pela atualização e pela reforma da LDA ganha impulso e necessidade, com o intuito de que os limites sejam regulamentados de maneira pertinente para os fins a que se destinam, visando a estabelecer maior acessibilidade aos usuários, além de garantias e limites às obras autorais (RODRIGUES, 2014).

Contudo, o acesso à internet e a ampliação das formas de compartilhamento de informações modificou o direito autoral, fazendo o ambiente digital se tornar um meio excelente para a violação não apenas dos limites dos direitos autorais, mas da própria redação do texto da LDA. Nesse contexto, o retrocesso tecnológico para a proteção dos direitos autorais não sei faz mais possível, visto que a Carta Maior já compreendeu que a internet é um direito fundamental e, embora seja um meio de fácil publicação de obras autorais das mais diferentes formas, o ambiente virtual tem condições ótimas para práticas condenáveis, o que fere diretamente os direitos do autor (ASCENSÃO, 2012).

Ainda que para os direitos autorais e de propriedade intelectual seja aplicado o princípio da territorialidade e que isso tenha funcionado de forma interessante na esfera penal, tal solução apenas se faz possível enquanto os atos são praticados diante dos meandros da legislação interna (ASCENSÃO, 2012). Todavia, na rede informática, inexistem fronteiras, o que põe em risco esses termos, surgindo a problemática da violação dos direitos do autor previstos na LDA, por atos praticados no exterior. Conforme Gomez e Back (2017, p. 39), em virtude disso, "[...] a utilização de uma criação intelectual navega sem previsão legal por entre as fronteiras, recebendo uma pluralidade de qualificações e mais, tornando possível, devido à facilidade de mudança de servidores, que sejam realizadas [...] violações em países com mais tolerância nesse domínio, tornando ineficaz a letra da lei nacional".

Enquanto a LDA não se adapta à nova realidade cibernética, faz-se válido o ensinamento de Ascensão (2012, p. 152), que ressalta que "[...] é muito primário pretender travar o processo tecnológico pela circunstância de esse progresso trazer consigo meios que podem ser usados para violar direitos de autor".

Assim, além da necessária reforma da LDA e da propriedade intelectual, cabe a discussão em relação ao sentido instrumental da propriedade intelectual, por meio do sopesamento das restrições do direito de acesso à cultura e ao conhecimento. Como a sociedade tecnológica passou a se desenvolver

diante das inovações de comunicação e compartilhamento de informações, há a indispensabilidade de serem novamente debatidos os parâmetros e limites jurídicos para satisfazer à nova configuração do processo autoral no ciberespaço (GOMEZ; BACK, 2017).



Exemplo

Confira a seguir alguns posicionamentos do STF sobre *fake news*, de acordo com Vinícius Borges Fortes e Wellington Antonio Baldissera, no artigo "Regulação das *fake news* e liberdade de expressão: uma análise a partir da reclamação 22.328 do Supremo Tribunal Federal", nas páginas 1 e 2:

> A partir da análise do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão reclamação 22.328, é possível encontrar fundamentos jurídicos para se estabelecer um controle sobre a disseminação de *fake news*, sem que exista desrespeito ao direito à liberdade de expressão?
>
> [...]
>
> A autorregulação regulada, com a menor intervenção possível do Estado sobre as *fake news*, preocupando-se em garantir o direito à liberdade de expressão, pode ser a melhor alternativa.

E segundo Bruno Meneses Lorenzetto e Ricardo dos Reis Pereira, no artigo "O Supremo Soberano no Estado de Exceção: a (des)aplicação do direito pelo STF no âmbito do Inquérito das 'Fake News' (Inquérito n. 4.781)", na página 1:

> Em 2019, o Presidente do STF instaurou uma investigação sigilosa para apurar supostas práticas de divulgação de notícias fraudulentas e infrações cometidas contra a Corte, seus membros e familiares. No curso desse Inquérito (nº 4.781), foram proferidas decisões marcadamente inconstitucionais que censuraram veículos da imprensa, tolheram liberdades e garantias processuais de cidadãos brasileiros e materializaram toda a sorte de arbitrariedades judiciais, sempre sob a justificativa de resguardo da ordem constitucional.

Referências

ASCENSÃO, J. O. *Direito autoral*. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

ASCENSÃO, J. O. Questões críticas do direito da Internet. *In*: WACHOWICZ, M.; PRONER, C. (org.). *Inclusão tecnológica e direito a cultura*: movimentos rumo à sociedade democrática do conhecimento. Florianópolis: FUNJAB, 2012. p. 39–68. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/35192626.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

ÁVILA, A. P. O.; WOLOSZYN, A. L. A tutela jurídica da privacidade e do sigilo na era digital: doutrina, legislação e jurisprudência. *Revista de Investigações Constitucionais*, v. 4, n. 3, p. 167–200, 2017. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/51295. Acesso em: 13 abr. 2021.

BEZERRA, A. C.; WALTZ, I. Privacidade, neutralidade e inimputabilidade da internet no brasil: avanços e deficiências no projeto do marco civil. *Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura*, v. 16, n. 2, p. 161–175, 2014. Disponível em: https://ridi.ibict.br/handle/123456789/858. Acesso em: 13 abr. 2021.

BITTAR, C. A. *Direito de autor*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BOBBIO, N. *A Era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet no Brasil. Brasília: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 13 abr. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Habeas Corpus 82424/RS*. Habeas-Corpus. Publicação de livros: anti-semitismo. Racismo. Crime imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Liberdade de expressão. Limites. Ordem denegada. Relator: Min. Moreira Alves, 17 de setembro de 2003. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur96610/false. p. 532. Acesso em: 13 abr. 2021.

CONRADO, M. M. *A arte nas armadilhas dos direitos autorais*: uma leitura dos conceitos de autoria, obra e originalidade. 2013. Tese (Doutorado em Direito) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/32966/R%20-%20T%20-%20MARCELO%20MIGUEL%20CONRADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 abr. 2021.

GANDELMAN, H. *De Gutenberg à Internet*: direitos autorais na Era digital. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1997.

GOMEZ, G. R.; BACK, A. Limites aos direitos autorais e as redes sociais. *Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacional (UNIBRASIL)*, v. 27, n. 2, p. 32–52, 2017. Disponível em: https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/cadernosdireito/article/view/3866/3137. Acesso em: 13 abr. 2021.

HARTMANN, I. A. M. O acesso à internet como direito fundamental. *E-Gov*: Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento, [2007]. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/ivar_hartmann.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

NOHARA, I. P. Desafios da ciberdemocracia diante do fenômeno das fake news: regulação estatal em face dos perigos da desinformação. *In*: RAIS, D. (coord.). *Fake news*: a conexão entre desinformação e o direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 75–90.

OLIVEIRA, A. S.; GOMES, P. O. Os limites da liberdade de expressão: fake news como ameaça à democracia. *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, v. 20, n. 2, p. 93–118, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.18759/rdgf.v20i2.1645. Acesso em: 13 abr. 2021.

OLIVEIRA, L. A. S. *O direito à liberdade de expressão eleitoral em tempos de fake news*. São Paulo: Dialética, 2021.

PECES-BARBA, G. *Derecho y derechos fundamentales*. Madrid: Centro de Derechos Constitucionales, 1993.

RAMOS, P. H. S. Neutralidade da rede e o marco civil da Internet: um guia para interpretação. *In*: LEITE, G. S.; LEMOS, R. (coord.). *Marco civil da Internet*. São Paulo: Atlas, 2014.

RODRIGUES, D. O. *Limites aos direitos de autor sob a perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos*: estudo dos limites aos direitos de autor frente aos direitos de acesso ao conhecimento e à educação nos ordenamentos internacional e interno. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) — Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-11022015-082708/publico/Dissertacao_Daniela_Oliveira_Rodrigues.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

SARLET, I. W. *A eficácia dos direitos fundamentais*: uma teoria geral dos Direitos Fundamentais na perspectiva constitucional. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

SARLET, I. W. Liberdade de expressão e o problema da regulação do discurso do ódio nas mídias sociais. *Revista Estudos Institucionais*, v. 5, n. 3, p. 1207–1233, 2019. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/428. Acesso em: 13 abr. 2021.

SILVEIRA, D. B. Paradigmas de interpretação constitucional: desafios ao entendimento das sociedades modernas. *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM*, v. 1, n. 1, p. 51–63, 2006. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/6764/pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

SOUZA, A. A. S.; SILVEIRA, D. B. Neutralidade de rede: núcleo de direito fundamental a Internet. *Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais*, v. 4, n. 2, p. 1–17, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330977789_NEUTRALIDADE_DE_REDE_NUCLEO_DE_DIREITO_FUNDAMENTAL_A_INTERNET. Acesso em: 13 abr. 2021.

TENÓRIO FILHO, G. M. F.; MALLMANN, Q. Os direitos autorais na era digital: desafios e novas perspectivas jurídicas. *PIDCC*, Ano VI, v. 11, n. 1, p. 177–189, 2017. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/012017/092017.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

WACHOWICZ, M.; WINTER, L. A. C. Os paradoxos da sociedade informacional e os limites da propriedade intelectual. *CONPEDI*, [2011]. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/luis_alexandre_carta_winter2.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

Leituras recomendadas

FORTES, V. B.; BALDISSERA, W. A. Regulação das *fake news* e liberdade de expressão: uma análise a partir da reclamação 22.328 do Supremo Tribunal Federal. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)*, v. 7, n. 3, p. 374–401, 2019. Disponível em: https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/671. Acesso em: 13 abr. 2021.

LORENZETTO, B. M.; PEREIRA, Ricardo dos Reis. O Supremo Soberano no Estado de Exceção: a (des)aplicação do direito pelo STF no âmbito do Inquérito das "Fake News" (Inquérito n. 4.781). *Sequência*, v. 85, p. 173–203, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.5007/2177-7055.2020v41n85p173. Acesso em: 13 abr. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Genebra: OMPI, 2002. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

VITORINO, M. M.; RENAULT, D. A irrupção das fake news no Brasil: uma cartografia de expressão. *Comunicação & Sociedade*, v. 42, n. 1, p. 229–259, 2020. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CSO/article/view/9398/7299. Acesso em: 13 abr. 2021.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
1
V.1 | 2023

Parte 3

Conceitos Fundamentais

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Conceitos fundamentais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Explorar a ciência do Direito Constitucional e o seu objeto.
- Expor a relação do Direito Constitucional com os outros ramos do Direito.
- Determinar o Direito Constitucional como o Direito de nível fundamental do ordenamento jurídico.

Introdução

O Direito Constitucional ou Direito Constitucional Positivo é o conjunto de normas jurídicas constitucionais, isto é, o conjunto de normas que forma o Estado, define os direitos e as garantias fundamentais, disciplina a relação entre os Poderes, entre outros assuntos.

O Direito Constitucional é o ramo do Direito especializado no estudo da Constituição, ou seja, das leis máximas de um Estado. Também chamada de Carta Magna ou Lei Maior, a Constituição se insere no topo do ordenamento jurídico, que é a relação hierárquica entre as leis. No Brasil, a Constituição é seguida por leis, decretos e jurisprudência, então pelos atos normativos e, na base, pelas demais normas. Tal analogia pressupõe que nenhuma lei subordinada pode desrespeitar a Constituição, ocasião em que se configura ação de inconstitucionalidade. Nesse ramo, avaliam-se as origens, a natureza e os efeitos do Texto Constitucional, bem como os responsáveis por redigi-lo. Neste capítulo, você vai ler sobre os principais elementos do Direito Constitucional.

Ciência do Direito Constitucional e o seu objeto

O Direito Constitucional está situado na clássica dicotomia jurídica entre Direito Público e Privado, como um dos ramos do primeiro. Essa tese clássica é imprestável na atualidade, tendo em vista a supremacia da Constituição e a constitucionalização do Direito (TAVARES, 2012).

Podemos distinguir o Direito Constitucional dos demais ramos do Direito Público pela natureza específica do seu objeto e pelos princípios peculiares que o informam. "Configura-se como Direito Público fundamental por referir-se diretamente à organização e ao funcionamento do Estado, à articulação dos seus elementos primários e ao estabelecimento das bases da estrutura política" (SILVA, 2017, p. 35).

Vocaciona-se à estruturação do Poder, fornecendo-lhe os contornos de atuação e limites da sua atividade, tendo sido, desde o final do século XX, o berço natural da positivação dos **direitos humanos**. Pragmaticamente, o Direito Constitucional (escrito) se identifica como um conjunto normativo especial: a Constituição do Estado, as suas leis constitucionais (no Brasil, chamadas de emendas à Constituição) e a jurisprudência constitucional definitiva (prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no Brasil, e por tribunais constitucionais, na maioria dos países da Europa) (TAVARES, 2012).

A Constituição (positivada de um país) é considerada um conjunto normativo fundamental, adquirindo, por isso, cada um dos seus preceitos a característica da superioridade absoluta, ou seja, da supremacia, em relação às demais normas de um mesmo ordenamento jurídico estatal (TAVARES, 2012).



Fique atento

A estrutura escalonada do Direito apresenta como ápice a Constituição, base a partir da qual todas as demais normas se desenvolvem e auferem sua validade última dentro do sistema. Dizemos que há um sistema quando as normas se reconduzem a uma única fonte de produção, mais ainda quando o Direito se reconduz, formal e procedimentalmente, a uma idêntica norma fundamental.

Resumidamente, então, podemos definir o Direito Constitucional como o ramo do Direito Público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado. Como esses princípios e normas fundamentais do Estado compõem o conteúdo das Constituições, podemos afirmar que o Direito Constitucional é a **ciência positiva das Constituições** (SILVA, 2017).

Jorge Miranda (1990, p. 138) define o Direito Constitucional como a:

> [...] parcela da ordem jurídica que rege o próprio Estado, enquanto comunidade e enquanto poder. É o conjunto de normas (disposições e princípios) que

> recordam o contexto jurídico correspondente à comunidade política como um todo e aí situam os indivíduos e os grupos uns em face dos outros e frente ao Estado-poder e que, ao mesmo tempo, definem a titularidade do poder, os modos de formação e manifestação da vontade política, os órgãos de que esta carece e os atos em que se concretiza.

A ciência do Direito Constitucional, portanto, significa a parcela dos estudos científicos que têm por objeto de pesquisa as normas constitucionais. Esse conjunto de estudos, por ter *status* científico, deve seguir uma série de princípios e regras que busquem assegurar a sua objetividade.

Maurice Hauriou (apud SILVA, 2017) declara que o Direito Constitucional tem por objeto a constituição política do Estado. Essa assertiva seria essencialmente verdadeira não fosse o sentido tão restrito que ele empresta ao conceito de constituição política.

Como domínio científico, o Direito Constitucional procura ordenar elementos e saberes diversos, relacionados a aspectos normativos do poder político e dos direitos fundamentais, que incluem:

- as reflexões advindas da filosofia jurídica, política e moral — filosofia constitucional e teoria da Constituição;
- a produção doutrinária acerca das normas e dos institutos jurídicos — dogmática jurídica;
- a atividade de juízes e tribunais na aplicação prática do Direito — jurisprudência.

Embora o conceito de ciência, quando aplicado às ciências sociais e, em particular, ao Direito, exija qualificações e delimitações de sentido, a ciência do Direito Constitucional desempenha papel análogo ao das ciências em geral. Nele, estão incluídos (BARROSO, 2010):

- a identificação ou elaboração de determinados princípios específicos;
- a consolidação e sistematização dos conhecimentos acumulados;
- o oferecimento de material teórico que permita a formulação de novas hipóteses, a especulação criativa e o desenvolvimento de ideias e categorias conceituais inovadoras testadas na vida prática.

A singularidade da ciência do Direito é que ela não pode servir-se, em escala relevante, da ambição de objetividade que caracteriza as ciências exatas ou as ciências naturais. Nesses domínios, as principais matérias-primas intelectuais são a observação, a experimentação e a comprovação, todas elas passíveis de

acompanhamento e confirmação objetiva por parte dos demais cientistas e da comunidade em geral. O Direito, todavia, não lida com fenômenos que se ordenem independentemente da atividade do intérprete, da sua subjetividade e da sua ideologia.



Fique atento

Ao contrário, por exemplo, do astrônomo, que observa e revela algo que lá já está, o jurista cria ele próprio o objeto da sua ciência. O Direito, a norma jurídica, não é um dado da realidade, mas uma criação do agente do conhecimento (BARROSO, 2010).

De modo geral, cabe ao Direito Constitucional o estudo sistemático das normas que integram a Constituição do Estado. Sendo ciência, há de ser forçosamente um conhecimento sistematizado sobre determinado objeto, e este é constituído pelas normas fundamentais da organização do Estado, isto é, pelas normas relativas a (SILVA, 2017):

- estrutura do Estado;
- forma de governo;
- modo de aquisição e exercício do poder;
- estabelecimento de seus órgãos;
- limites de sua atuação;
- direitos fundamentais do homem e respectivas garantias;
- regras básicas da ordem econômica e social.

Relação do Direito Constitucional com os outros ramos do Direito

O Direito Constitucional costuma ser inserido como ramo do Direito Público, junto com o Direito Administrativo, Internacional, Criminal, Tributário e Processual. Essa ideia, contudo, não pode mais prosperar, na medida exata em que a Constituição passou a ocupar um papel central para todos os ramos do Direito, sejam matérias públicas ou privadas. Assim, por exemplo, o Código Civil, classicamente compreendido dentro do Direito Privado, não deixa de sofrer o influxo constante dos preceitos constitucionais. Essa **constitucionalização do Direito** — que exige a leitura de todas as leis, sejam públicas ou

privadas, administrativas ou civis e comerciais, a partir e de acordo com os ditames da Constituição do País — aloca o Direito Constitucional (e a Constituição é seu coração) na posição especial de tronco dos sistemas normativos atuais de modelo ocidental. Nesse sentido, podemos dizer que: "[...] o Direito Constitucional alimenta os demais Direitos, que só podem prosperar e florescer validamente dentro desse sistema de alimentação" (TAVARES, 2012, p. 46).

Na realidade, portanto, o Direito Constitucional é a base de todos os demais Direitos disciplinados, no Brasil, por leis (leis complementares, ordinárias, delegadas), medidas provisórias e decretos. Portanto, o Direito Constitucional é a base, o fundamento dos demais Direitos, seja qual for a repartição que se queira (ou não) realizar entre eles (TAVARES, 2012).

O Direito Constitucional não poderia estar contido, portanto, em um dos clássicos ramos do Direito, pois é superior, englobante e serve de fundamento de validade a todos. Alocando-o no Direito Privado, teríamos a equivocadíssima impressão de que não guarda relação ou contato com o Direito Privado, a não ser secundária e episodicamente, quando é justamente o oposto que deve ocorrer (TAVARES, 2012).

Direito Constitucional e Direito Administrativo — O Direito Constitucional antecede o Direito Administrativo. Este tem como origem o limite de poder que se inaugura com a submissão do Estado ao princípio da legalidade. Quando a norma jurídica igualmente vincula o administrado e o administrador, é possível constituir, com autonomia científica, uma área própria de conhecimento dedicada ao estudo do regime jurídico da Administração Pública. O Direito Administrativo é considerado o setor do Direito mais afim ao Direito Constitucional, ou seja, são as duas disciplinas mais próximas em seus institutos e conceitos. Entre Direito Constitucional e Direito Administrativo, há uma diferença de grau. O Direito Constitucional trata das regras gerais da função pública. Já o Direito Administrativo realiza o detalhamento das funções. Além disso, há um conjunto de regras na Constituição que pertencem ao Direito Administrativo propriamente dito: as normas sobre desapropriação (arts. 182, 184 e 185); sobre os poderes do Presidente e as funções dos ministros de Estado (arts. 84 e 87, parágrafo único); e, finalmente, as normas sobre Administração Pública (arts. 37 a 43).

Direito Constitucional e Direito Tributário — Todos os princípios aplicáveis à atividade tributária do Estado encontram-se consignados na Constituição. Por esse motivo, assinala com absoluta propriedade Carrazza que "A Constituição Federal, no Brasil, é a lei tributária fundamental, por conter as diretrizes básicas aplicáveis a todos os tributos". Íntimo se mostra o rela-

cionamento entre esses dois setores do Direito. Tendo em vista que a maior parte da arrecadação do Estado se deve à tributação, a estreita proximidade entre o Direito Constitucional e o Tributário não poderia ser ignorada. Por ser atividade estatal, há de subsumir-se às normas jurídicas, como, de resto, toda a ação praticada pelo Poder Público. No caso, contudo, há o componente constitucional, que, basicamente, decorre de dois elementos. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que a tributação interfere na liberdade e na propriedade das pessoas, direitos fundamentais que só poderiam ser alcançados pelo próprio contorno que lhes conferiu o constituinte em seu ato originário de elaborar as normas constitucionais. Em segundo lugar, a tributação sustenta, no caso dos Estados federativos, a autonomia dos diversos membros federados. Por isso, seria inimaginável atribuir ao Poder Legislativo central a competência para realizar a partilha de competências tributárias, uma vez que equivaleria a praticamente negar qualquer possibilidade de contar com uma federação forte.

Direito Constitucional e Direito Penal — A relação entre Direito Penal e Direito Constitucional é profunda e inegável. A Constituição é o marco fundamental do ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito, o que faz todas as normas estarem vinculadas e subordinadas aos comandos constitucionais. Isso quer dizer que o Direito Constitucional exerce influência sobre todos os ramos do Direito e, particularmente, sobre o Direito Penal. Os próprios bens jurídico-penais encontram raízes materiais na Carta Magna, assim, cabe ao Direito Penal a tarefa de tutelar os direitos fundamentais nela insculpidos. A leitura atenta dos direitos fundamentais consagrados pelas diversas Constituições bem demonstra que em todas encontraremos normas próprias (em sua origem histórica) do campo penal. Assim, podemos mencionar, *verbi gratia*, o princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A Constituição brasileira de 1988 trata de diversas garantias dessa índole (art. 5º, XXXVII a LXVII).

Direito Constitucional e Direito Processual — No campo do processo, houve a constitucionalização, a exemplo do que ocorrera com o Direito Penal, de inúmeros princípios. Assim, temos um conjunto de normas que podemos chamar de princípios constitucionais do processo. Podemos citar, na Constituição brasileira de 1988, as seguintes normas processuais: a) assistência judiciária (art. 5º, LXXIV); b) mandado de segurança (art. 5º, LXIX); c) ação popular (art. 5º, LXXIII).

Direito Constitucional e Direito Internacional — O art. 4º, I a X, da Constituição trata dos princípios que regem a atuação internacional do Estado brasileiro. Assim, menciona:

> I — independência nacional;
> II — direitos humanos;
> III — autodeterminação dos povos; e
> IV — igualdade entre os Estados.

Direito Constitucional e Direito do Trabalho — Ramo do Direito Privado, formado por um conjunto de normas que regem as relações entre trabalhadores e empregadores. Amplo é o rol de direitos do trabalhador assegurados constitucionalmente (arts. 6º a 9º).

Direito Constitucional e Direito Privado — A Constituição trata do amparo à família, aos filhos e aos idosos (arts. 226 a 230) e da defesa do consumidor (art. 5º), entre outras normas voltadas para a regulamentação do Direito Privado.

Direito Constitucional como o direito de nível fundamental do ordenamento jurídico

Recebe o nome de **ordenamento jurídico** todo o conjunto de leis de um Estado, que agrupa Constituição, leis, emendas, decretos, resoluções, medidas provisórias, entre outras. No Brasil, o ordenamento jurídico nacional tem origem na tradição romano-germânica ou civilista. A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor desde 5 de outubro de 1988, é a lei suprema do País, definindo-o como uma República Federativa, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal.

O Direito Constitucional é um ramo do Direito Público, fundamental à organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado. Nesse papel de direito público fundamental, o Direito Constitucional estabelece:

- a estrutura do Estado;
- a organização de suas instituições e órgãos;
- o modo de aquisição e exercício do poder;
- a limitação desse poder, por meio, especialmente, da previsão dos direitos e das garantias fundamentais.

O Direito Constitucional é muito mais do que um ramo do Direito Público. Ele consubstancia a matriz de toda a ordem jurídica de um específico Estado. Figurativamente, o Direito Constitucional é representado como o tronco do qual derivam todos os demais ramos da grande árvore que é a ordem jurídica de determinado Estado (essa imagem tem o mérito de representar a unidade do Direito — por definição, indivisível —, consubstanciada na árvore, e esclarecer que a alusão a ramos tem função puramente didática) (SILVA, 2017).

Como produto legislativo máximo do Direito Constitucional, encontramos a própria Constituição, elaborada para exercer dupla função: garantia do existente e programa ou linha de direção para o futuro.

A Constituição deve ser idealizada como lei fundamental do sistema jurídico. Para que uma norma possa ser válida, devemos descobrir seu valor nessa lei afirmada como fundamental. Ela tem a obrigação de estar em conformidade com o ordenamento jurídico, na medida em que a lei fundamental dispuser, ou seja, a Constituição irá indicar a direção, pois é o conjunto de teorias de onde os conhecimentos derivam, a direção para as demais normas de hierarquia inferior, pois estas assim obterão a validade necessária, encontrarão sua base na lei fundamental, passando a integrar o ordenamento jurídico (MORAES, 2003).

Ensina Hans Kelsen que a Constituição é a norma fundamental, a qual dá validade a todas as demais normas de um sistema jurídico, e salienta:

> Mas a criação da Constituição realiza-se por aplicação da norma fundamental. Por aplicação da Constituição, opera-se a criação das normas jurídicas gerais através da legislação e do costume; e, em aplicação destas normas gerais, realiza-se a criação das normas individuais através das decisões judiciais e das resoluções administrativas. Somente a execução do ato coercivo estatuído por estas normas individuais — o último ato do processo de produção jurídica — se opera em aplicação das normas individuais que a determinam sem que seja, ela própria, criação de uma norma. A aplicação do Direito e, por conseguinte, criação de uma norma inferior com base numa norma superior ou execução do ato coercivo estatuído por uma norma (KELSEN, 2003, p. 261).

Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do País, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas (KELSEN, 2003).

Podemos afirmar que a estabilidade da Constituição Federal está ligada à aplicação exata do princípio constitucional da **segurança jurídica**. E, para se obter essa estabilidade e segurança, dispõe a Constituição do controle concentrado de constitucionalidade, com a previsão da ação declaratória de constitucionalidade e de inconstitucionalidade e também do controle difuso, aprimorado por meio da Emenda Constitucional nº. 45, de 30 de dezembro de 2004. A emenda instituiu a concessão para a edição de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, buscando, com essa modificação constitucional, a estabilidade e a segurança proclamadas, para as hipóteses em que a Suprema Corte não mantém o controle concentrado de constitucionalidade.



Saiba mais

Para saber mais sobre a Constituição Federal como vértice do sistema jurídico, leia o livro *A força normativa da Constituição*, de Konrad Hesse, traduzido por Gilmar Ferreira Mendes.



Referências

BARROSO, L. R. *Curso de Direito Constitucional contemporâneo:* os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

KELSEN, H. *Teoria pura do Direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

MIRANDA, J. *Manual de Direito Constitucional*. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1990. t. 1.

MORAES, A. de. *Direito Constitucional*.13. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

SILVA, J. A. da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

TAVARES, A. R. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

Leituras recomendadas

HESSE, K. *A força normativa da Constituição*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009.

MENDES, G. F.; COELHO, I. M.; GONET, P. G. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2014.

NOVELINO, M. *Curso de Direito Constitucional*. 12. ed. Salvador: Jus Podium, 2017.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
1
V.1 | 2023

Parte 4

Instituições do Direito Privado: Sujeitos de Direito Privado

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Instituições de Direito Privado: sujeitos de Direito Privado

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os sujeitos de Direito Privado.
- Distinguir os sujeitos de Direito Público dos sujeitos de Direito Privado.
- Reconhecer cada um dos sujeitos de Direito Privado, conforme a sua regulamentação.

Introdução

O sujeito de direito são as pessoas a quem a lei atribui a faculdade ou a obrigação de agir, exercendo poderes ou cumprindo deveres. Os sujeitos de direito são todos os indivíduos e entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidades de direitos e responder por deveres jurídicos. Assim, conceituamos sujeito de direito como a interpretação ampla da pessoa. Ou seja, há sujeitos de direito que não são pessoas físicas nem jurídicas. Todavia, não há direito sem sujeito, pois todo direito é de alguém.

Neste capítulo, você vai ler sobre as instituições de Direito Privado para, então, analisar os sujeitos de Direito Privado.

Sujeitos de Direito Privado

Conforme trata o art. 1º do Código Civil, o ser humano, para ser considerado sujeito de direitos e deveres, basta existir. Dessa forma, a pessoa é o sujeito de direito dotado de capacidade plena ou ilimitada na ordem civil, então toda pessoa é dotada de personalidade, isto é, tem capacidade para figurar em uma

relação jurídica. Com exceção dos animais e dos seres inanimados, todos têm competência genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.

Nessa linha, o art. 1º do Código Civil, ao proclamar que toda "pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil" (BRASIL, 2002, documento on-line), combina o conceito de capacidade com o de personalidade. Portanto, os entes não personificados são sujeitos de direito dotados de capacidade civil limitada à sua proteção ou à consecução dos seus fins.

Já o art. 2º do Código Civil aborda a distinção entre pessoa e nascituro, dispondo que pessoa é o ser humano nascido com vida e o nascituro é o ser humano não nascido ou ainda em ventre materno. Todavia, ambos são sujeitos de direito, personalizado e não personalizado, respectivamente.

Os **sujeitos de direito não personalizados** são os seres humanos concebidos ou não, aos quais o direito empresta consequências jurídicas ou tutela, não havendo a necessidade, para esses casos, de se atribuir personalidade. Dessa forma, são sujeitos de direito:

- o nascituro (art. 2º do Código Civil);
- os embriões excedentários, concebidos *in vitro* e ainda não implantados no útero de mulher, crioconservados até 3 anos da concepção, desde que considerados aptos para procriação (art. 1.597, IV, do Código Civil);
- os ainda não concebidos, entes humanos futuros ou prole eventual, destinatários de sucessão testamentária (art. 1.799, I, do Código Civil), ou de outros negócios jurídicos unilaterais, ou de estipulações em favor de terceiro;
- as futuras gerações humanas, como titulares de preservação do meio ambiente, que lhes permita vida digna, quando nascerem (art. 225 da Constituição Federal).

A capacidade é a medida da personalidade. A capacidade, presente no art. 1º do Código Civil, é a que todo indivíduo possui, pois é a capacidade de direito, de aquisição ou de gozo de direitos. No entanto, não são todos os indivíduos que possuem essa capacidade de fato, que é a aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil. Dessa maneira, os recém-nascidos e os amentais sob curatela têm somente a capacidade de direito, podendo, por exemplo, herdar, mas não havendo a capacidade de fato.

Há, ainda, o sujeito de direito na forma das pessoas jurídicas, que são apresentadas na forma de entidades que a lei empresta personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. A **personalidade jurídica** é

diversa da dos indivíduos que a compõem, pois inicia no momento do registro da pessoa jurídica no órgão competente. O registro corresponde à inscrição do contrato social ou estatuto perante o órgão competente, surgindo, com esse ato, a personalidade jurídica da própria pessoa jurídica, distinta, portanto, da personalidade dos seus membros.

O Código Civil, art. 44, traz o rol de pessoas jurídicas de Direito Privado assim consideradas pela lei:

> Art. 44 São pessoas jurídicas de Direito Privado:
> I — as associações;
> II — as sociedades;
> III — as fundações.
> IV — as organizações religiosas;
> V — os partidos políticos.

A sua capacidade plena de direitos inicia conforme preceitua o art. 45 do Código Civil:

> [...] com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo (BRASIL, 2002, documento on-line).

Esse é o marco inicial da sua existência, em que seus representantes passam a responder por direitos e obrigações da pessoa jurídica de Direito Privado.

As associações são compostas pela reunião de pessoas físicas, para realização de um fim comum, sem fins lucrativos. Nesse sentido, ensina Tartuce (2015, p. 162): "As associações, pela previsão legal, são conjuntos de pessoas, com fins determinados, que não sejam lucrativos. Assim deve ser entendida a expressão 'fins não econômicos'".

O Enunciado nº. 534 do Conselho da Justiça Federal (CJF) do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que as associações podem exercer atividade econômica, porém sem a finalidade de ganho econômico, ou seja, lucro. São exemplos as associações de moradores e associações de empregados.

As sociedades reúnem pessoas com a finalidade de exercer uma atividade empresária, com intuito de obter retorno financeiro, ou seja, lucro. Sejam elas sociedades empresariais ou sociedades simples, possuem uma finalidade lucrativa.



Fique atento

A mera reunião de pessoas, sem personalidade jurídica, conforme exige a legislação (com o seu ato constitutivo, registro, representantes e outros), não constitui uma pessoa jurídica de Direito Privado. Assim, a família ou até mesmo uma sociedade irregular, sem as formalidades exigidas pela legislação, não são consideradas pessoas jurídicas de Direito Privado.

As fundações se constituem a partir do patrimônio destinado a um determinado fim específico, sendo esse patrimônio derivado de testamento ou escritura pública. As fundações de Direito Privado nada têm de relação com as fundações estatais, que são autárquicas e pertencentes ao objeto de estudo do Direito Administrativo.

Os partidos políticos e as organizações religiosas foram incluídos no rol de pessoas jurídicas de Direito Privado pela Lei nº. 10.825, de 22 de dezembro de 2003, tornando-se entidades autônomas e diferentes das associações. As constituições das organizações religiosas não podem sofrer qualquer interferência do Poder Público, e a criação de partidos políticos deve seguir o que estipula a lei. O Quadro 1 apresenta a distinção entre personalidade e capacidade jurídica.

Quadro 1. Distinção entre personalidade e capacidade jurídica.

Personalidade jurídica	Consiste na aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil.
Capacidade jurídica	**Conceito:** é a maior ou menor extensão dos direitos de uma pessoa. É, portanto, a medida da personalidade. **Espécies:** ■ de **direito** ou de **gozo**, que é a aptidão que todos possuem (art. 1º do Código Civil); ■ de **fato** ou de **exercício**, que é a aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil. Quem só possui a de **direito** tem capacidade **limitada**. Quem possui também a de **fato** tem capacidade **plena**.
Distinção entre capacidade e legitimação	**Capacidade** não se confunde com **legitimação**. Esta é a aptidão para a prática de **determinados** atos jurídicos, uma espécie de capacidade especial exigida em certas situações. A sua ausência não acarreta a incapacidade.

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2014, p. 59).



Fique atento

A pessoa é o ente a quem a ordem jurídica confere poderes. A capacidade é a aptidão para adquirir direitos ou exercê-los, por si ou por outrem. O conjunto desses poderes é a personalidade jurídica, sendo a capacidade um elemento da personalidade.

A regra, portanto, é a capacidade. A incapacidade é exceção. A primeira exprime poderes ou faculdades, sendo a personalidade resultante desses poderes. A incapacidade civil é a restrição ao poder de agir e, pela característica de restrição, vem expressamente prevista em lei, podendo ser absoluta ou relativa.

A incapacidade será absoluta quando houver proibição total do exercício do direito, acarretando a nulidade do ato quando praticado pelo próprio incapaz.

Incapacidade absoluta — São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Incapacidade relativa — são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer nos termos do Código Civil.

I — os maiores de 16 e menores de 18 anos;
II — os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;
III — aqueles que, por causa transitório ou permanente, não puderam exprimir sua vontade;
IV — os pródigos.

Distinguir os sujeitos de Direito Público dos sujeitos de Direito Privado

No ramo do Direito, há situações em que o Estado se relaciona com o particular como se fosse outro indivíduo no mesmo plano jurídico — as chamadas **relações contratuais privadas** —, mas, regra geral, as relações entre o Estado e os demais são chamadas de **relações de Direito Público**.

Nas relações de Direito Privado, os indivíduos estão em um mesmo patamar de igualdade, diferente das relações de Direito Público, em que o Estado pode exercer prerrogativas, pois é representante dos interesses da coletividade. Ade-

mais, nessas relações, as normas jurídicas concedem uma série de privilégios ao Estado e aos seus agentes, nas relações com os particulares.

Tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas são sujeitos de direito, mas não são aplicadas as mesmas regras quanto ao começo e fim da personalidade, nem quanto à capacidade, pelo que não podem ser tratadas indistintamente.

Assim, os sujeitos de Direito Público podem ser:

- as pessoas jurídicas de Direito Público externo, sendo os países e as organizações internacionais;
- as pessoas jurídicas de Direito Público interno, sendo os Estados, municípios, o Distrito Federal e as autarquias.

Conforme o art. 41 do Código Civil (BRASIL, 2002, documento on-line):

> At. 41 São pessoas jurídicas de Direito Público interno:
> I — a União;
> II — os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
> III — os municípios;
> IV — as autarquias, inclusive as associações públicas;
> V — as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Por outro lado, os sujeitos de Direito Privado são compostos pelas pessoas jurídicas apresentadas pelo art. 44 do Código Civil, que diz:

> Art. 44 São pessoas jurídicas de Direito Privado:
> I — as associações;
> II — as sociedades;
> III — as fundações;
> IV — as organizações religiosas;
> V — os partidos políticos.
> § 1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento.
> § 2º As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código.
> § 3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica (BRASIL, 2002, documento on-line).

Dessa forma, a ordem jurídica admite duas espécies de pessoas:

- as pessoas naturais, também chamadas de pessoas físicas;
- as pessoas jurídicas.

É, no entanto, na capacidade de ser titular de direitos e obrigações que a personalidade se mede, influindo na capacidade de agir não só o estado do agente, mas também certas qualidades jurídicas, como, por exemplo, a de empregado.



Saiba mais

Tanto o Direito Público como o Direito Privado formam um conjunto de leis que lhe são inerentes, sendo que uma lei não pode pertencer, ao mesmo tempo, aos dois conjuntos.

- **Direito Público** — é o conjunto de normas interligadas entre si, regulando as atividades do Poder Público, ou seja, a atividade da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, das autarquias e das demais entidades de caráter público, criadas por lei.
- **Direito Privado** — é o conjunto de normas interligadas entre si, regulando as atividades dos particulares.

O melhor critério para averiguar se a norma pertence ao Direito Público ou ao Direito Privado é o subjetivo, que está na verificação do sujeito da relação jurídica fixado pela lei, visto que esta estabelece uma relação jurídica entre o poder atribuído ao sujeito ativo e o dever que incumbe ao sujeito passivo. Se em um de seus polos está situado o Poder Público (a União, o Estado-membro, o Distrito Federal, o município, suas respectivas autarquias, entre outros), a lei faz parte do Direito Público; não figurando o Estado ou o Poder Público como tal em um de seus polos, pertence ela ao Direito Privado.

Sujeitos de Direito Privado conforme a sua regulamentação

Entre os sujeitos de Direito Privado — aqueles que regulamentam as relações entre particulares —, temos, no Brasil, grande parte da regulamentação e das normas disposta no Código Civil. Todavia, temos também como sujeitos de Direito Privado as áreas de:

- Direito Empresarial;
- Direito do Consumidor;
- Direito do Trabalho;
- Direito Internacional Privado.

Com isso, os sujeitos de Direito Privado são disciplinados pelas normas jurídicas, leis e demais regras encontradas no Direito Civil, Direito Empresa-

rial, Direito Internacional Privado e Direito do Trabalho, tendo como sujeitos envolvidos nessas relações os cidadãos comuns, pessoas físicas, podendo ser também pessoas jurídicas ou, ainda, pessoas jurídicas de Direito Público, na forma de empresas públicas ou o próprio Estado, somente quando não esteja utilizando do seu poder político ou jurisdicional.

Nessa relação, o ramo do Direito Civil é a disciplina regulada pelo Código Civil, dispondo sobre:

- as relações pessoais puras, ou seja, as normas que regulam o Estado e a capacidade das pessoas;
- as relações de família, patrimoniais e extrapatrimoniais, decorrentes do vínculo de sangue ou do parentesco civil e das relações hereditárias do patrimônio;
- as relações puramente patrimoniais, sendo as que envolvem compra e venda de imóveis, locação, posse, servidão e usufruto.

Ainda no ramo do Direito Civil, são apresentados alguns ramos específicos, que, por terem características de direitos específicas e pontuais, são reguladas em leis apartadas do Código Civil, divididas em:

- Direito do Consumidor;
- Direito de Locação;
- Direito Autoral;
- Direito do Menor.

O Direito Empresarial, antigamente chamado de Direito Comercial, disciplina as relações características da profissão do comércio, ou seja, relação em que pelo menos uma das partes é comerciante ou industrial. O Direito Empresarial é regulado no Código Civil, enquanto o Direito Comercial trata apenas de algumas normas do comércio marítimo.

Temos ainda o ramo que disciplina o Direito do Trabalho, sendo a disciplina regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que traz as normas jurídicas da relação entre os empregados e empregadores. Enquanto nas relações cíveis comuns as partes têm igualdade de condições, nas relações trabalhistas, uma das partes, geralmente o empregador, possui capacidade econômico-financeira superior à capacidade do trabalhador.

Por último, temos o ramo do Direito Internacional Privado, regulado por meio de tratados e convenções legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, podendo ser interno ou internacional. Esse ramo visa disciplinar os conflitos

de legislações estrangeiras, compreendendo as regras que regulamentam os problemas ocasionados pelo conflito de leis entre países nos quais as pessoas concentrem seus interesses. Assim, o Direito Internacional Privado trata de:

- conflitos de leis;
- intercâmbio universal ou comércio internacional;
- extraterritorialidade das leis.

Ele versa sobre duas perspectivas de ordens jurídicas:

- uma só ordem, ou seja, quando para solução de um problema independe de outro ordenamento jurídico senão o próprio do país;
- duas ou mais ordens jurídicas, ou seja, quando para solução de um problema é preciso considerar o ordenamento jurídico de um outro país.



Referências

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 16 maio 2018.

FIGUEIREDO, F. V. *Direito Civil.* São Paulo: Saraiva, 2014.

TARTUCE, F. *Manual de Direito Civil:* volume único. 5. ed. São Paulo: Método, 2015.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.



CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é evoluir.

Av. Victor Barreto, 2288 | Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br